

1501188-87.2019.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... por se tratar de produto do tráfico. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 228/243), requer a absolvição do réu por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Requer também, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11343/06, pois o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501188-87.2019.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501188-87.2019.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra EVANDRO SANTOS DE SOUZA, qualificado a fls. 04, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na data de 21 de dezembro de 2019, na Rua Silvério Valim, 1 esquina com Rua Aubina Maria Picinini, por volta das 22h20, nesta cidade e comarca, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava, para fins de fornecimento a terceiros, (i) 23,29 gramas de cocaína, na forma de crack; (ii) 5,03 de cocaína, na forma de crack, e (iii) 13.3 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo conforme o e auto de exibição e apreensão de fls. 09/10. Segundo se apurou, os policiais militares receberam informação sobre tráfico de drogas e ocultação em um terreno baldio e se posicionaram observando local. Em monitoramento, avistaram o indiciado adentrando no terreno e ao dele sair, efetuaram a abordagem, encontrando em seu poder porção de droga crack que revelou

peso de 5.03 gramas. Em continuidade dos trabalhos policiais, em varredura no terreno e no local onde havia se posicionado, encontraram um frasco contendo 32 porções de cocaína e uma porção de maconha, razão pela qual exararam voz de prisão em flagrante delito. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga apreendida seria destinada à entrega a consumo alheio. É certo que a conduta dos denunciados envolveu a adolescente Vitória de Oliveira Dias.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial. Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 114/118), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 123), o despacho de fls. 143/147, de 2 de setembro de 2020, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Foi instaurado incidente de verificação de dependência toxicológica no acusado (apenso - P. 0009065-33.2020.8.26.0482), onde o perito, após a realização do exame, concluiu que o réu não apresenta quadro de doença mental ou perturbação da saúde mental, e que não havia prejuízo da capacidade de entendimento e de determinação à época do fato pelo conceito da actio libera in causa.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 216/222), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, pugnando pela perda do dinheiro apreendido por se tratar de produto do tráfico. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 228/243), requer a absolvição do réu por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Requer também, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11343/06, pois o réu alegara em Juízo ser usuário de drogas, bem como no incidente de verificação de dependência toxicológica, restou demonstrado que o réu é usuário, tendo o médico-perito sugerido o acompanhamento e tratamento por período de dois anos. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, sendo o réu primário e de bons antecedentes, que lhe seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado com a redução em seu patamar máximo, substituindo a pena corporal por restritiva de direitos, por fim, que lhe seja restituído os bens, inclusive o dinheiro, que ficou devidamente demonstrado que o réu trabalhava diuturnamente, e que a pena seja fixada no regime aberto. É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9/10; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 27/29; pelo laudo químico

toxicológico de fls. 67/69, atestando - Item A (Acondicionado sob o lacre 0032676 )

Descrição: um invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó e trinta um invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo "zip") encerrando porção de material sólido particulado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 23,12 grama(s) - vinte e três gramas e doze centigramas. Massa Líquida: 11,9 grama(s) - onze gramas e nove centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item B (Acondicionado sob o lacre 0032674 ) Descrição: invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando uma porção de material sólido Petrificado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 7,63 grama(s) - sete gramas e sessenta três centigramas. Massa Líquida: 4,71 grama(s) - quatro gramas e setenta um centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada

delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de

03/08/2020); Item C (Acondicionado sob o lacre 0032675) Descrição: invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 16,15 grama(s) - dezesseis gramas e quinze centigramas. Massa Líquida: 11,84 grama(s) - onze gramas e oitenta quatro centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Laudo pericial de objetos de fls. 70/73, que analisou- 1 (um) recipiente cilíndrico com tampa, em bom estado de conservação, da marca "Estrela Alimentos", de tampa vermelha no formato de rosca e recipiente transparente de formato ovalar, dotado de etiqueta com as inscrições "VINAGRETE", "Salsichas" "Aperitivo". RESULTADO: FOI DETECTADA A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA TETRAHIDROCANABINOL (THC) substância listada em Portaria 344/1998 SVS/MS -Lista F2 (Lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil), usando-se a metodologia I descrita no anexo deste Laudo, e FOI DETECTADA A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA COCAÍNA, substância listada em Portaria 344/1998 SVS/MS - Lista F1 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil), usando-se a metodologia II descrita no anexo deste laudo; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Angelo de Faccio Junior, sob o crivo do contraditório declarou que receberam várias denúncias e informações de que haveria tráfico de drogas naquele local e para lá se dirigiram, contudo, sem a viatura, para não alarmar. Visualizaram que o réu iluminava o terreno com um celular e entrava e saía lá de dentro do terreno. Observaram que o réu pegou um objeto nas mãos, resolveram abordá-lo. Com ele foi encontrado uma pedra bruta de crack e mais trinta e duas porções de cocaína, esta, dentro de um pote, mas o pote não lhe pertencia e não soube dizer a quem pertencia. Ele pegava parte da droga e levava para uma praça que fica ali próximo e que a droga era dele para seu consumo. Dentro do pote, ainda foram encontradas trinta e uma porções de cocaína ainda para embalar e uma porção de maconha. Com ele também foi encontrada a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais). Diante dos fatos foi encaminhado para a Delegacia e lhe dado voz de flagrante. Afirma que o Evandro morava há trinta metros do local onde foi encontrado com as drogas. A diligência foi realizada no período noturno. As denúncias foram passadas por viciados e vizinhos próximos à casa dele, que viam que ele entrava e saía do terreno baldio. Fizeram observação de campo somente no dia da prisão do réu. Afirma que no momento em chegaram e ingressaram no terreno onde estava a residência até quando ele saiu levou uns cinco minutos. Confirma que as diligências começaram por volta de 22 horas, foi a noite mesmo, ficando há uma distância de três a quatro metros, escondidos atrás de um arbusto. A iluminação era da via pública e do celular enquanto ele estava mexendo nas drogas. Não acionou o cão de faro para descobrir onde estava as drogas, pode ver onde estavam o local onde ficava o pote com as drogas. Dava para ver exatamente de onde estavam o local que ele mexia e era onde estava a droga, e assim que ele saiu, o abordamos, momento em que dispensou essa pedra de crack e depois localizamos o pote onde teríamos visto esse pote. A porção que ele trazia no bolso, disse-nos que era para seu consumo, também tinha cerca de R\$ 70,00 (setenta reais) e ele não conseguiu explicar sobre o dinheiro. O pote encontrado com mais drogas estava escondido embaixo de uma pedra que tampava o local, e indagado sobre essas porções ele disse que não lhe pertencia. Fizeram buscas na residência do réu e nada de ilícito foi localizado, nem dinheiro, salvo engano. Toda a abordagem durou cerca de 15 a 20 minutos, depois foram até a casa dele que durou cerca de 20 a 30 minutos. Esse foi todo o tempo das diligências, incluindo o terreno e a casa dele. Assim que adentraram na residência que ficava no terreno, ele logo deixou o terreno. No momento da abordagem ele dispensou cerca de cinco gramas e não tinha com ele nenhuma balança ou petrechos para embalagem. Afirma que encontraram o pote de imediato, assim que ele foi abordado, e iniciaram a revista pessoal. O pote com drogas estava há uns três ou quatro metros de distância do acusado. A pedra estava em cima do pote. O acusado chegou a pé no local, e no momento da abordagem não verificaram o celular do acusado. Afirma que o réu estava lúcido, muito lúcido no momento da abordagem.

O PM Eder Mazzini Brassan, sob o crivo do contraditório declarou que estava em patrulhamento com a equipe de BAEP em Presidente Prudente e receberam informações de que o réu iria levar crack para uma praça próxima a sua residência, que ele deixava as drogas escondidas num terreno baldio também próximo a sua casa. Nesse terreno havia um veículo e uma casa de madeira, ambos abandonados. Optou com seu parceiro, deslocarem-se de modo furtivo e ficarem dentro dessa casa em observação, essa casa é de madeira e não tem portas. Puderam observar quando o réu chegou no terreno e iluminava com o seu aparelho celular, indo aos fundos e pegou um pote plástico, retirou algo de dentro e ia saindo do terreno quando o abordamos e ele dispensou uma porção de crack ao chão de aproximadamente cinco gramas, afirma que essa pedra fracionada, dá para fazer mais ou menos umas trinta pedras para consumo de usuários. Retornaram ao terreno onde estava o pote plástico e encontraram dentro deste, salvo engano, mais trinta e uma porções de cocaína e mais uma porção de maconha, ainda R\$ 70,00, em dinheiro. Indagado, assumiu a propriedade do crack, dizendo que era para seu consumo, e as demais disse não saber a quem pertencia. Diante disso, deram-lhe voz de prisão por tráfico pois já sabiam que ele estava traficando e aquele pote plástico, foi de onde ele teria mexido, conduzindo-o ao distrito policial com as drogas e objetos. Confirma que já receberam notícias há muito tempo de que Evandro estava praticando o tráfico de drogas naquele bairro. Afirma que ingressaram no terreno pelos fundos, haja vista que na frente mora alguns parentes do réu. Na rua do fundo, tem um barranco com bananeiras, por onde subiram e chegaram ao terreno, o fundo também é um terreno vazio. Durante a abordagem não esboçou desejo de fugir, não teve nem como, pois foi surpreendido pela equipe. Ao se posicionarem no terreno até a abordagem do réu não levou mais que vinte minutos que ficaram ali em campana, foi bem rápido. Durante a abordagem, não verificaram o aparelho celular do réu, pois chegou parentes dele, não se recorda se ele liberou a senha para averiguar o seu celular, porém, não havia nenhuma informação de interesse na ocorrência, também não se recorda se teria utilizado ou mexido no aparelho dele. As cinco gramas de crack encontrada com ele, não tinha semelhança com aquelas encontrada no pote, o crack era uma pedra bruta, que comumente os traficante fazem é andar com ela bruta, vai quebrando e fracionando, e como disse, daria para fazer umas trinta pedras para venda. Quer deixar consignado que não se lembra se foi utilizado o telefone do réu ou da sua mãe para ligar para outra viatura, pois como ficaram a pé, estavam sem comunicação, pois deixaram o rádio na viatura. Afirma que foi feita vistoria na residência do réu e nada de ilícito foi localizado, no terreno e na casa também não foi encontrada nenhuma balança ou petrecho para embalar ou endolar a droga para venda, pois a cocaína já estava pronta para venda, somente o crack ainda estava em pedra bruta. Disse que no local que ficou, no barraco de madeira, ficava há pouco mais de três metros de onde ele pegou a droga no pote, então não precisaram realizar mais nenhuma diligência, pois quando ele chegou iluminando o local com a lanterna do celular, deu para ver nitidamente ele encontrando o pote, abrindo e pegando a droga de dentro, depois fechou e guardou. Após ele desligar a lanterna não foi possível mais visualizar, somente depois em diligência conseguiu localizar com a sua lanterna o pote onde ele teria mexido, pegando algo de dentro. Disse que havia umas folhas e o pote estava embaixo das folhas, algumas sujeiras, alguns objetos. Durante a abordagem estava acompanhado do Cb Angelo, e ficaram mais dois policiais na viatura, pois sempre a equipe é composta por quatro policiais de BAEP, eles se afastaram do bairro, pois se alguém visse a viatura no local, com certeza se comunicariam por app de celular e o traficante não iria realizar o comércio ilícito. Foi a primeira vez que vistoriou aquele local, mas já tinha passado naquela rua e abordado outras pessoas, mas já sabia que ele fazia o tráfico naquele terreno, mas no dia chegou informação precisa de onde ele escondia a droga. Afirma que a casa dele ficava há cerca de 150 metro do local, mais ou menos, o veículo gol pertencente ao réu Evandro ficou estacionado próximo, mas de onde estava, não conseguiu ver se ele chegou de carro ou não, mas este veículo estava próximo. Confirma que no pote só tinha cocaína e maconha. O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, , inclusive, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP.PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))”.

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” - “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi unânime, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

O réu Evandro Santos de Souza, em seu interrogatório declarou que nunca foi preso e cumpriu pena de prisão, somente cumpriu pena de prestação de serviço à comunidade. Sobre os fatos disse que no dia do ocorrido, tinha ido ao salão cortar o cabelo e depois voltou para rua da casa da sua avó, parando o carro na rua, portanto uma porção de crack que iria usar, pois é usuário. Quando saiu do veículo, entrou no terreno, e como no local é comum bastante gente ir lá usar droga, a dona ou seus

parentes trancavam a porta com cadeado, e foi pelo fundo do terreno, sentou no meio da mata, acendeu a lanterna do seu celular e pegou a lata onde ia usar a droga, arrumou tudo e usou a droga, e quando a droga fez efeito, ficou com medo de continuar ali e saiu correndo com o restante do crack na mão para fora do terreno, quando passou pelo portão, os policiais saíram de dentro da casa, com arma em punho e apontaram para seu rosto, pegando pelo seu pescoço perguntando o que estava fazendo no terreno e o que tinha na mão. Disse que estava usando o crack, foi quando soltou o que tinha nas mãos e eles pegaram. Mandaram ajoelhar no chão e o algemou, perguntando se ainda tinha alguma coisa onde estava, mas negou que tivesse, foi então que o levaram para a frente do terreno e nada tinha sido localizado. Entraram novamente no terreno, e ficaram o tempo todo perguntando onde tinha mais droga, e dizia que não tinha, foi quando eles entraram para dentro novamente, e após uns 20 a 25 minutos, um deles lhe pegou e o levou para dentro do terreno novamente, e um deles abriu o potinho e jogou um monte de porção de cocaína dentro. Não sabia o que tinha dentro e lhe perguntaram "e essa droga aí, vai dizer que não é sua", e lhe disseram que era cocaína, tendo dito que não usava cocaína, que desconhece, a única droga que era sua, era o crack. Deram-lhe tapa na cara e perguntaram se não iria abraçar a droga, tendo dito que não, porque aquela droga não era sua, apenas o crack que encontraram em sua mão. Fizeram-no sentar novamente na calçada e foram até sua casa e trouxeram seu tio, momento em que disseram que se caso não abraçasse aquela droga iria levar seu tio preso, então disse que não poderia abraçar porque não era sua, apenas o crack, a cocaína desconhece, pois não usa, apenas usa crack, liberam seu tio e o colocaram dentro da viatura. Pegaram a chave da sua casa e do carro, revistaram o carro e depois sua casa, após isso voltaram e o levaram para a Gurgel para formalizar o flagrante. Disse que na Delegacia disse a mesma coisa, que o crack era para seu uso e a cocaína desconhece, porque não é sua. Disse que entrou com o crack na mão, era uma porção pequena, e não dava para fazer 50 porções, como disse os policiais. Comprou na vila da sua casa, perto do bar, com uns meninos, e não fuma em sua casa porque sua esposa não aceita. A polícia encontrou também R\$ 70,00 contigo, porque sua mãe lhe dera R\$ 120,00, pois quando tinha vontade de fumar vendia as coisas que estavam no seu carro, aparelho de som, tênis ou alguma roupa sua, quando então teria discutido com sua mãe dizendo que precisava de dinheiro para comprar gasolina para colocar no seu carro e cortar o cabelo, e ainda disse que queria sair com sua esposa para comer um lanche, e perguntou para ela se tinha algum dinheiro para lhe arrumar. Sua mãe então lhe deu R\$ 120,00 e com ele comprou R\$ 50,00 de crack para usar e sobrou os R\$ 70,00 no bolso. Afirma que em fevereiro foi preso por tráfico novamente. A abordagem durou mais de 40 minutos. Não acompanhou a vistoria em sua casa, ficou sentado na calçada. No momento em que foi abordado no terreno não tinha pote perto, só depois que o pegaram, mandaram ajoelhar e soltar o crack que estava em sua mão, soltou, pegaram o dinheiro que estava em seu bolso e lhe revistaram e algemaram. Perguntaram se de onde eu tinha vindo teria mais droga, disse que não, era aquela para usar, mas o levaram junto para vistoriar o terreno, ficaram procurando durante uns 5 a 10 minutos no lugar onde estava e não encontraram nada, depois o levaram para frente da casa e o mandaram sentar. Disse que entrou pela frente do terreno, e foi abordado após uns 5, 6 ou 7 minutos, foi o tempo de entrar, sentar e preparar um para fumar e sair. Afirma que pegaram o celular na mão, e como eles mandaram ficar de cabeça baixa, não sabe se eles mexeram no seu celular, mas pegaram o celular na mão. Não tinha balança, tesoura ou faca no local. É usuário de crack há uns 8 anos após a morte de seu pai, começou a andar com pessoas que usava e acabou usando. Por dia, geralmente, fuma de 5 a 10 ou até 15 gramas, se deixar. No momento da abordagem, tinha acabado de usar a droga. Afirma que seu veículo também foi vistoriado.

A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria dele pelo réu, além disso, há vários desencontros em sua versão, sempre apresentando justificativas e narrativas vazias, principalmente quanto ao dinheiro apreendido que disse ter recebido de sua mãe R\$ 120,00 e comprou R\$ 50,00 de crack e o restante iria sair

com a esposa para comer lanche e também colocar gasolina em seu veículo. Não é crível que essa quantia pudesse servir para realizar todos esses desejos, até porque, poderia ter trazido a Juízo sua mãe para confirmar essa versão, ou até mesma sua esposa, bem como seu tio, já que em seu interrogatório em Juízo, também indicou o tio na sua trama, dizendo que a polícia teria ido até a casa de seus parentes e o trouxeram na tentativa de lhe pressionarem a assumir a propriedade da droga encontrada dentro do pote no terreno, porém, a D. Defesa não se dignou a arrolar o tio, a genitora e nem a esposa como testemunhas para confirmar sua versão dos fatos, já que seria imprescindível seus testemunhos para corroborar com toda a sua narrativa, dessa forma, cai em total descrédito diante de tudo o que foi amealhado aos autos.

O réu Evandro também tenta a todo tempo confundir com sua narrativa, na tentativa de desvencilhar da acusação, dizendo que foi abordado e algemado, e ficou sentado na calçada enquanto os policiais diligenciavam dentro do terreno para tentar localizar mais drogas, depois o levaram novamente para dentro do terreno e nada localizaram, difícil crer nessa versão, uma vez que como não indicou onde estava o pote com as drogas, eles foram procurar o encontraram, e depois disso ele disse que ficou sentado na calçada enquanto os policiais foram diligenciar dentro da casa dele, mas momentos antes disso, ele disse "...liberam seu tio e o colocaram dentro da viatura. Pegaram a chave da sua casa e do carro, revistaram o carro e depois sua casa, após isso voltaram e o levaram para a Gurgel..."

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, vez que, segundo a Polícia Militar, usuários e a vizinhança já vinham denunciando o tráfico de drogas no local, pois que, cansados da atividade criminosa do réu, acabam denunciando-o, mesmo que depois seja de difícil sua identificação, acabam por serem descobertos e presos.

Todavia, é fato que nenhuma testemunha que more próximo ao local dos fatos tenha coragem de testemunhar, haja vista que vemos corriqueiramente que são ameaçadas, bem como seus familiares, pois são sempre cometidos tais crimes em bairros mais carentes, onde as pessoas são muito próximas, o que inviabiliza sua identificação, tendo a Polícia que se esconder e caminhar a pé até os locais, porque, muitas vezes são vistos por amigos e olheiros que denunciam ao traficante a chegada da guarnição da Polícia Militar, tornando difícil a concretização com sucesso dessas incursões. Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta dos réus, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga, mas também o dinheiro que, certamente, acabara de receber da venda do entorpecente, o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada aos demais objetos e a droga, crack, várias porções de cocaína e maconha dentro de um pote de plástico, o que condiz com a conduta do traficante, já embaladas para a venda.

Por tudo isso, demonstrada, a saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu naquele, e que sua palavra não merece crédito algum, restando isolada nos autos. Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, juntamente com o dinheiro (R\$ 70,00), denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias

que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava naquela residência abandonada, de onde retirava parte para a venda a terceiro na pracinha, enquanto a maior parte ficava escondida na residência dos fundos do terreno.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas naquele local, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Em que pese confirmar que foi preso por tráfico de drogas no mês de fevereiro daquele ano, não há qualquer informação nesse sentido dentro dos autos, de modo que não há como valorar tal assertiva, e que de sua folha de antecedentes, bem como da certidão de distribuição de processos, constata-se ser ele primário.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis idem bis.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por



si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminoso. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006).

Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. [...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem

caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA,

Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]". (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVANO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]". (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]". (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário e não registra antecedentes, e as circunstâncias judiciais do artigo 59, lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, ausente quaisquer circunstância agravante ou atenuante a serem consideradas.

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade técnica, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

As quantidades de drogas e de dinheiro apreendidos em poder do réu são diminutas, sendo possível crer que ele não se trata de criminoso contumaz.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga e o pouco de dinheiro apreendido com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplica do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital da Esperança de Presidente Prudente(Hospital do Câncer).

Em caso de revogação das penas restritivas de direitos, o réu cumprirá a pena corporal fixada nesta sentença no regime aberto.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu EVANDRO SANTOS DE SOUZA, RG: 40505390, CPF: 242.485.218-90, nascido em 16/06/1994, natural de Presidente Prudente - SP, filho de ODAIR JOSE SOUZA e MARTA LUCIA DOS SANTOS, a cumprir a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital da Esperança de Presidente Prudente(Hospital do Câncer); e a pagar a multa de valor correspondente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, cada dia no valor mínimo legal, por violação do artigo 33, caput, c/c o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos